CY Cergy Paris Université

Faculté de Droit

Année universitaire 2026-2027

TRAVAUX DIRIGES – **2ème année Licence Droit**
DROIT DES OBLIGATIONS
Cours de madame la professeure Magali Jaouen

PREMIÈRE SÉANCE

semaine du 21 septembre 2026

LES SOURCES DE L'OBLIGATION

Cette première séance de travaux dirigés est l'occasion d'explorer les différentes sources d'obligations reconnues en droit français. Aux fins d'éprouver les classifications retenues par le code civil et de maîtriser les catégories et notions fondamentales, l'exemple du contentieux des loteries publicitaires sera pris comme fil conducteur de la séance. Ce contentieux permet en effet de comprendre, tout d'abord, la flexibilité et la porosité des catégories juridiques (délit, engagement unilatéral, contrat, quasi-contrat) qui ne sont pas des données du réel, mais de pures constructions de l'esprit destinées à appréhender, voire, à façonner le réel que sont les faits et conflits d'intérêts. Il illustre ensuite à merveille la capacité de renouvellement permanent du système juridique et donc l'idée que le « vide juridique » n'existe pas ! A cette occasion, c'est la catégorie, controversée, des quasi-contrats qui sera mise plus particulièrement à l'honneur. Les documents et exercices proposés vont vous conduire à explorer la richesse de notre droit des obligations et vous sensibiliser au « jeu de l'esprit » que constitue toute entreprise de qualification juridique.

Documents

Document n° 1 : Schéma de la classification des sources de l'obligation

Document n° 2 : **Cass. civ. 1re, 28 mars 1995**, n° 93-12678, *Bull. civ.* I, n° 150

Document n° 3 : **Cass. civ. 2e, 28 juin 1995**, n° 93-17738, *Bull. civ.* II, n° 225

Document n° 4 : **Cass. civ. 1re, 19 octobre 1999**, n° 97-10570, *Bull. civ.* I, n° 289

Document n° 5 : **Cass. civ. 2e, 11 février 1998**, n° 96-12075, *Bull. civ.* II, n° 55

Document n° 6 : **Cass. ch. mixte**, **6 septembre 2002**, n° 98-22981, *Bull. C. Mixte*, n° 4

Document n° 7 : **Cass. civ. 1re, 10 juillet 2013**, n° 12-20849, inédit

Document n° 8 : D. Mazeaud, « D'une source, l'autre… », note sous Cass. ch. mixte, 6 sept. 2002, *D.* 2002, n° 39, p. 2963

Document n° 9 : D. Fenouillet, « Loteries publicitaires : pour un droit efficace ! », *RDC* 2007, n° 3, p. 788

Exercices

EXERCICES :

1° **LIRE et RESUMER les notes figurant aux documents n° 8 et 9**

2° Réalisez une **fiche d'arrêt pour CHACUN des arrêts** communiqués dans la fiche (doc 2 à 7). Vous devrez également identifier **la structure de chaque arrêt** (mention en marge : visa, faits, procédure, argumentation du pourvoi, motifs Cour d'appel, motifs cour de cassation, etc...

3° Depuis l'ordonnance de 2016, **quelle est la nouvelle numérotation des anciens articles du Code civil dont il est fait application dans ces arrêts** ?

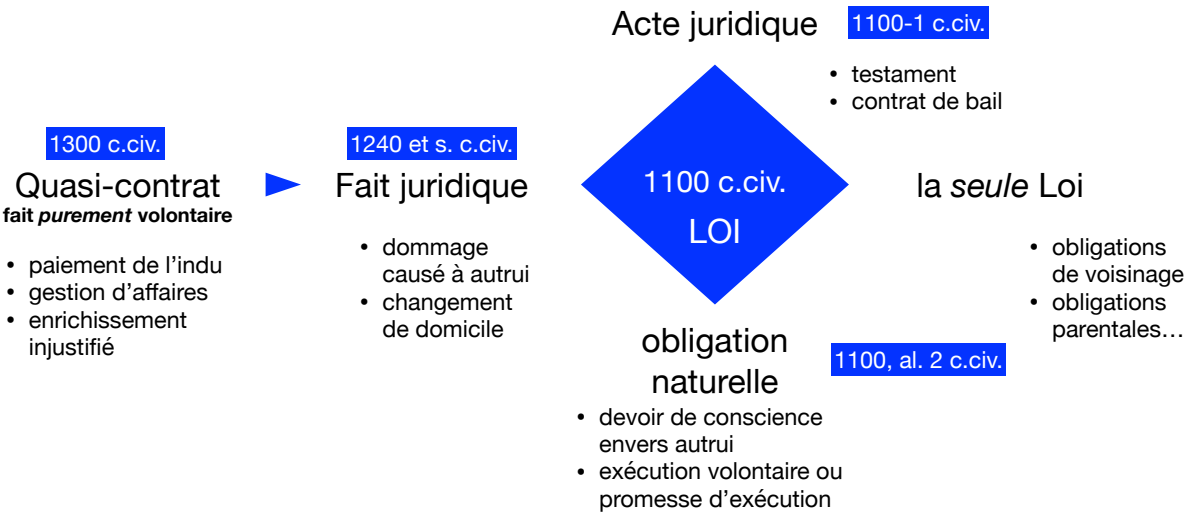
N.B. Pour vous accompagner dans la réalisation des exercices, un **fascicule de méthodologie** est mis à disposition sur votre ENT. Nul besoin d'insister sur la nécessité de le lire et de le consulter régulièrement tout au long de l'année.

Pour cette séance, la **lecture des conseils méthodologiques suivants est indispensable :**

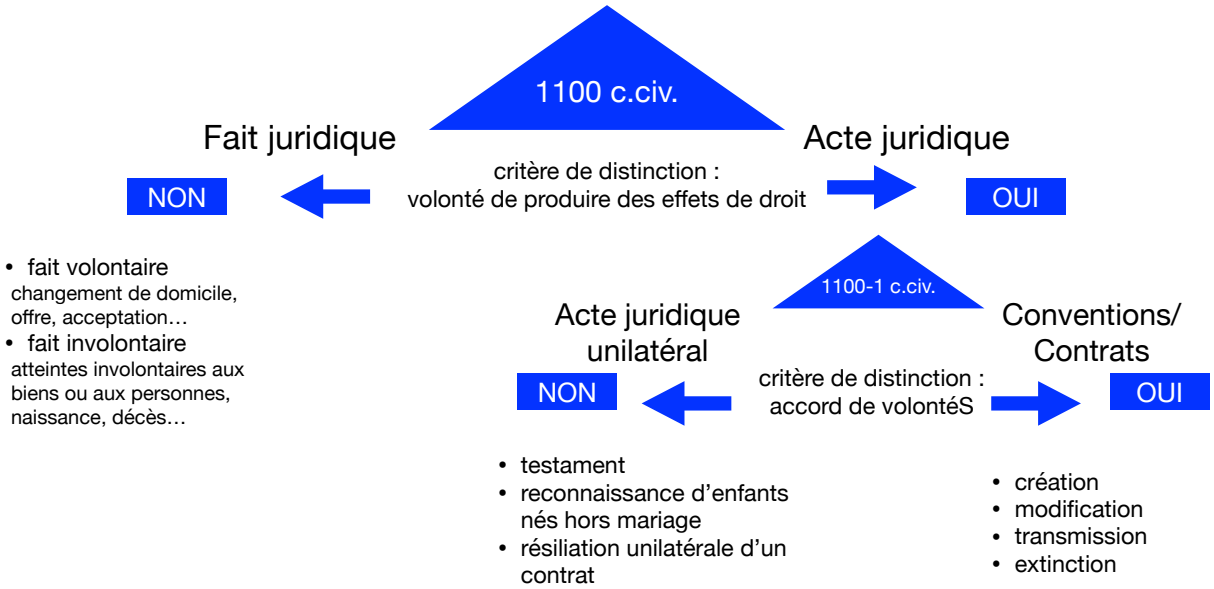
- La lecture des arrêts de la Cour de cassation (v. not. structure des arrêts)
- La méthode du commentaire (et plus particulièrement, la fiche d'arrêt)

Document n° 1 : Schéma de la classification des sources de l'obligation

Les sources de l'obligation (1)



Les sources de l'obligation (2)



Document n° 2 : **Cass. civ. 1re, 28 mars 1995**

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a reçu, en mai 1990, de la société Inter-Selection, entreprise de vente par correspondance, une lettre accompagnée d'une attestation lui certifiant que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué ; qu'il a réclamé le paiement de la somme de 150 000 francs révélée après grattage et correspondant, selon lui, sans autre condition à ce numéro et assortie de la remise d'une automobile pour avoir répondu dans le délai fixé ; que la société Inter-Selection a prétendu que ce numéro avait seulement participé à un pré-tirage au sort pour des prix en espèces encore en jeu ;

Attendu que la société Inter-Selection reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 1993) d'avoir accueilli les demandes de M. X... alors, selon le moyen et de première part, qu'en se bornant à relever que les documents reçus par M. X... pouvaient légitimement laisser penser à celui-ci qu'il avait gagné sans rechercher si à l'origine du tirage au sort effectué par huissier, ce sont ces prix qui devaient revenir à l'attribution de son numéro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en jugeant que l'attestation mentionnait le numéro de M. X... comme " étant un numéro gagnant ayant participé au tirage au sort pour un prix en espèces " constituait un engagement unilatéral de volonté de cette dernière l'obligeant à reconnaître à M. X... la qualité de gagnant des lots litigieux, la cour d'appel a également, violé les textes précités ; alors, de troisième part, que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'interprétation donnée par M. X... des documents reçus correspondait à la perception d'un consommateur moyen pour en déduire l'attribution des prix litigieux quand il lui appartenait de rechercher si ces documents excluaient que la volonté de l'organisateur du jeu pût s'interpréter différemment ; alors, enfin, que l'attestation que le numéro de M. X... était de ceux qui " ont participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces " ne pouvait s'entendre comme informant son destinataire que ce tirage l'avait désigné gagnant d'un prix en espèces et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette attestation ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire non seulement de l'attestation mais aussi de sa lettre d'accompagnement que la cour d'appel a retenu, de la part de la société Inter-Selection, l'engagement de payer à M. X... le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Document n° 3 : **Cass. civ. 2e, 28 juin 1995**

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 1993), que Mme X... a reçu de la société Ompex (la société) un catalogue de vente par correspondance ainsi que divers documents publicitaires l'informant que son nom avait été retenu pour participer à un jeu dans le cadre duquel divers lots étaient attribués ; qu'elle a reçu, ultérieurement, un autre document intitulé " 2e information aux gagnants du 4e tirage " lui indiquant " maintenant, c'est sûr, vous avez gagné un deuxième prix au titre du 4e tirage " et comportant une définition des prix attribués dans les termes suivants : " 2e prix :
60 000 francs " complétés par la mention " les prix suivants seront remis lors du 4e tirage : 2e prix, bijoux avec pierres précieuses " ; que ses demandes de remise du prix étant restées sans réponse, Mme X... a assigné la société en paiement de la somme de 60 000 francs avec intérêts de droit ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer cette somme à titre de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, l'appréciation du caractère éventuellement trompeur d'un document adressé par une société de vente par correspondance au gagnant d'une loterie sur la valeur du lot désigné par tirage au sort doit se faire in abstracto par référence au consommateur moyen ; qu'en se bornant à rechercher si la rédaction du document litigieux était de nature à induire en erreur Mme X... sur la valeur du lot devant lui être attribué, au lieu de se référer au consommateur moyen, normalement intelligent et attentif, doté d'un esprit normalement critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir analysé les documents diffusés par la société Ompex, que la rédaction de celui intitulé " 2e information aux gagnants du 4e tirage ", compte tenu des termes utilisés, notamment du fait que le " 2e prix " était défini comme portant sur une valeur de 60 000 francs constituée " de bijoux avec pierres précieuses " sans allusion à une quelconque division de ce dernier entre divers attributaires était de nature à persuader Mme X... que son numéro tiré au sort lui avait permis de se voir attribuer un prix d'une valeur de 60 000 francs ;

Qu'en l'état de ses énonciations la cour d'appel, qui a caractérisé une faute de la société Ompex, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Document n° 4 : **Cass. civ. 1re, 19 octobre 1999**

Attendu que les époux X... ont reçu, en 1993, de la société Civad Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée " tirage exceptionnel du blanc " ; que cet envoi était composé d'un imprimé intitulé " titre de propriété " mentionnant en petits caractères qu'il faisait " office de bon de participation ", d'une photographie d'une maison et d'un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement du jeu, devant être renvoyé, avec ou sans commande d'article, accompagné du " titre de propriété " ; qu'à ces pièces était jointe une lettre personnalisée indiquant aux destinataires " vous êtes propriétaires " et les invitant à vérifier si le numéro porté sur le " titre de propriété " correspondait au numéro affecté à l'un des dix lots mentionnés en marge de cette lettre ; que le numéro du " titre de propriété " envoyé aux époux X... correspondant d'après la liste à une maison, les intéressés ont demandé l'attribution de ce lot ; que la société les a informés qu'un autre participant au jeu avait gagné la maison ; que l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1996) a décidé qu'en faisant parvenir aux époux X... des documents publicitaires équivoques, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme inférieure à la valeur de la maison le montant de la condamnation mise à la charge de la société, alors, selon le moyen, que l'existence d'un engagement unilatéral oblige celui dont il émane à exécuter l'obligation qui en est l'objet ; qu'en les déboutant de leur demande, tout en constatant que la lettre personnalisée qui leur avait été adressée contenait l'emploi de l'indicatif présent " vous êtes propriétaires ", situé au troisième paragraphe, précédé par un premier paragraphe annonçant qu'un huissier de justice vient de désigner les numéros gagnants des titres de propriété, et par un deuxième paragraphe qui invite ledit destinataire à se reporter aux numéros imprimés en marge de la lettre dont celui de tête, affecté à une maison d'une valeur de 420 000 francs, correspondait précisément au numéro figurant sur le " titre de propriété " des époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1103 et 1108 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les documents publicitaires envoyés aux époux X... étaient équivoques, la cour d'appel n'a donc pas retenu la volonté certaine de la société de leur attribuer la maison litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Document n° 5 : **Cass. civ. 2e, 11 février 1998 (Extraits)**

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1996), qu'à la suite d'une commande qu'elle avait passée à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, Mme X... a reçu de celle-ci la notification officielle d'un gain de 250 000 francs ; que Mme X... après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin ;
(…)

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'un engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l'encontre d'une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l'offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition ; que, dans son arrêt avant dire droit du 18 octobre 1995, la cour d'appel, se livrant à une analyse complète de la lettre de la société France direct service du 25 mars 1992, avait relevé que Mme X... n'y était présentée que comme une des gagnantes possibles du prix de 250 000 francs qu'elle devrait partager avec d'autres, que cette lettre valait seulement " notification de participation au gain de 250 000 francs " et que sa destinataire ne pouvait recevoir éventuellement un prix que " si votre numéro personnel est reconnu gagnant ", d'où une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par la société FDS que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise, et que cette société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement affiché ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs visés au moyen, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société FDS était tenue par son engagement, accepté par Mme X..., à payer à cette dernière la somme promise de 250 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n° 6 : **Cass. ch. mixte**, **6 septembre 2002 (Extraits)**

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a reçu de la société de vente par correspondance Maison française de distribution (la société) deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné 105 750 francs, avec annonce d'un paiement immédiat, pourvu que fût renvoyé dans les délais un bon de validation joint ; que cette pièce fût aussitôt signée et expédiée ; que la société n'ayant jamais fait parvenir ni lot ni réponse, M. X... l'a assignée en délivrance du gain et, subsidiairement, en paiement de l'intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort ; que l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a demandé le paiement d'une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ;

que l'arrêt leur a respectivement accordé les sommes de 5 000 francs et un franc ;

(...) sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l' article 1371 du Code civil ;

Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ;

Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient qu'en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d' un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M. X... avait cru gagner ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a condamné la société MFD à verser à M. X... la somme de 5 000 francs, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Document n° 7 : **Cass. civ. 1re, 10 juillet 2013**

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir qu'elle avait reçu de la société Agence de marketing appliqué différents documents lui annonçant qu'elle avait gagné des sommes d'argent, mais n'avait pu obtenir la délivrance de ses gains, Mme X... a fait assigner cette société en paiement de ces sommes ;

Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt énonce que si les documents publicitaires adressés à Mme X..., destinés à l'inciter à passer commande, entretiennent volontairement une ambiguïté de par les termes employés, leur formulation, leur emplacement, pouvant laisser croire, au vu d'une lecture incomplète, que la destinataire était effectivement gagnante des gains annoncés, il est toutefois mentionné le règlement du jeu qui indique clairement l'aléa par un nouveau tirage au sort, que la nécessité de prendre connaissance du règlement est mise en évidence par la mention en gras et lettres capitales "A lire attentivement - règlement officiel et complet du jeu", que la présentation du règlement s'avère suffisamment lisible, même si elle demande une certaine attention qui peut légitimement être exigée de la part du bénéficiaire potentiel au regard des enjeux financiers, que ce procédé commercial largement répandu est en outre connu du grand public et ne peut sérieusement abuser une personne de cet âge, née en 1954, recevant à plusieurs reprises en quelques mois des annonces de gains différents ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'annonce des gains ne mettait pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Agence de marketing appliqué aux dépens ;

Document n° 8 : D. Mazeaud, « D'une source, l'autre… »

1 - Qu'on se le dise, désormais tous ceux qui ont le privilège d'enseigner, dans les facultés de droit de France et de Navarre, le droit des obligations vont devoir quelque peu bousculer leurs habitudes !

D'une part, en guise d'introduction à leur enseignement, il leur sera difficile, pour peu qu'ils se défient du droit savant et se préoccupent du droit vivant, de présenter les sources des obligations en distinguant, avec une superbe assurance, les engagements qui procèdent de la volonté de s'engager, autrement dit d'un acte juridique, et ceux qui ne découlent pas d'une telle volonté, c'est-à-dire d'un fait juridique. Il leur faudra, aujourd'hui encore plus qu'hier, notamment à la lumière de la jurisprudence relative aux loteries publicitaires organisées par des entreprises de vente par correspondance, concéder que la qualification de la source de l'obligation repose parfois sur de simples considérations d'opportunité, et peut même varier du tout au tout, à savoir de l'acte au fait, en raison de considérations purement formelles, qui tiennent au libellé du document dans lequel la volonté du débiteur s'est manifestée.

D'autre part, ils devront probablement revoir à la hausse la part réservée aux quasi-contrats, à titre de sources d'obligations. Traditionnellement, ce n'est qu'après avoir navigué, pendant de très longues heures, sur le fleuve tumultueux du contrat et les océans déchaînés du délit et du quasi-délit, que l'on embarque nos amphithéâtres pour une rapide croisière sur le paisible ruisseau du quasi-contrat. Avec l'arrêt rendu le 6 septembre par la Chambre mixte (1), il faudra sans doute revoir nos plans de navigation pour s'apprêter à affronter la tempête quasi contractuelle que la Cour de cassation a pris le risque de déclencher.

2 - Comme d'habitude, il s'agissait d'un consommateur qui, à la lecture d'un document qui lui avait été adressé par une entreprise de vente par correspondance, croyait avoir gagné le « gros lot », en l'occurrence une somme de 105 750 francs, qu'il pensait recevoir à la seule condition de renvoyer le bon de validation joint. Bien qu'il ait obtempéré, le consommateur ne reçut pas le moindre centime et décida d'assigner le marchand d'illusions perdues en paiement du gain promis, alors qu'une association de consommateurs réclama, pour sa part, à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs, une somme de 100 000 francs. Parce qu'ils contestaient la « générosité » des juges du fond qui, pour réparer leurs préjudices respectifs, leur avaient accordés 5000 francs et un franc, le consommateur et l'association ont formé un pourvoi. Si la Chambre mixte a rejeté le pourvoi formé par la personne morale, elle a, en revanche, en réponse à celui du consommateur, censuré la décision des juges du fond, dans des termes qui méritent d'être reproduits. Au visa de l'article 1371 du code civil, la Chambre mixte, après avoir rappelé que « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers les tiers », en a déduit que « l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».

3 - Voilà donc le quasi-contrat appelé à la rescousse, pour permettre la mutation de l'illusion créée dans l'esprit du consommateur en obligation à la charge de l'entreprise,

organisatrice d'une loterie ! Après avoir, dans ses arrêts précédents, sollicité en vain toutes les autres sources d'obligations pour mettre fin à ces pratiques commerciales douteuses, la Cour de cassation exploite donc aujourd'hui le flou et l'imprécision du code civil, à propos de la notion de quasi-contrat (2), et s'y engouffre pour unifier le droit en ce domaine et imposer, grâce au droit commun, la moralité et la sécurité que le droit spécial de la consommation a été incapable d'instaurer.

L'entreprise est audacieuse et mérite, à ce titre, d'être saluée. Après tout, cette tentative de sortir le quasi-contrat du rôle résiduel dans lequel, depuis deux siècles, la doctrine l'a, à quelques exceptions près (3), frileusement cantonné a quelque chose de franchement réjouissant, à condition d'admettre que le droit, en général, et le droit des sources des obligations, en particulier, n'est pas figé pour l'éternité et se prête au mouvement perpétuel des idées, fruit de l'imagination et de l'inventivité.

Reste que, pour apprécier les mérites de la solution, il convient, pour savoir si, en l'espèce, le quasi-contrat ne constitue pas *une source hasardeuse* (II), de revenir sur les décisions antérieures de la Cour de cassation, ce qui nous conduira inéluctablement à constater qu'à propos de la question tranchée par la Chambre mixte, dans cet arrêt, les *sources* sont *capricieuses* (I).

I - Sources capricieuses...

Pour retenir à la charge des entreprises de vente par correspondance, organisatrices de loteries publicitaires, une obligation, la Cour de cassation a successivement considéré que leur engagement avait pour source leur volonté de s'engager, soit *un acte juridique* (A), ou leur comportement, indépendamment d'une telle volonté, soit un *fait juridique* (B).

A - Acte juridique

4 - A deux reprises au moins, la première Chambre civile de la Cour de cassation n'a pas hésité à exploiter cette source mal-aimée que constitue encore, dans la doctrine contemporaine, l'engagement unilatéral de volonté pour prendre, à leur propre piège, les entreprises de vente par correspondance. Dans un premier arrêt (4), elle a décidé que les juges du fond, par une interprétation souveraine des documents envoyés au consommateur, avaient pu retenir l'existence d'un engagement unilatéral de payer la somme d'argent promise. Dans le second (5), elle a, certes, rejeté le pourvoi formé par le consommateur, au moyen duquel « l'existence d'un engagement unilatéral oblige celui dont il émane à exécuter l'obligation qui en est l'objet », mais uniquement parce que les conditions requises, pour qu'une volonté solitaire puisse créer une obligation à la charge de celui qui l'émet, n'étaient pas réunies. En effet, en l'espèce, la cour d'appel avait souverainement estimé que les documents publicitaires étaient équivoques et, par conséquent, avait légitimement décidé que la volonté certaine de la société de s'obliger faisait défaut. Cette seconde décision ne refoulait donc pas, par principe, l'engagement unilatéral de volonté comme source de l'obligation de l'entreprise défenderesse, mais rappelait simplement que la fermeté et la précision de la volonté solitaire sont les mamelles de cette source spécifique d'obligation.

5 - Outre la volonté isolée, c'est aussi à la volonté plurielle que la Cour de cassation a, à quelques reprises, songé pour condamner les entreprises de vente par correspondance à exécuter leurs promesses sans lendemain. Dans quelques arrêts (6), en effet, la Cour a

considéré qu'un contrat s'était formé en raison de la rencontre des volontés émises par l'entreprise et le consommateur. Celle-là, en envoyant les documents dans lesquels elle annonçait la fausse bonne nouvelle de gain, avait émis une offre de contracter que le consommateur avait acceptée en renvoyant, non sans allégresse, son bulletin de jeu dûment rempli et signé. Dès lors, le refus de payer la somme promise pouvait s'analyser comme une inexécution illicite de l'engagement auquel s'était obligée l'entreprise indélicate, qui engendrait sa responsabilité contractuelle.

6 - Si ces deux sources volontaires, que sont l'engagement unilatéral de volonté et le contrat, présentent toutes deux un immense avantage, dans la perspective de la protection du consommateur, à savoir le paiement intégral du gain escompté, elles sont atteintes d'un vice que d'aucuns stigmatisent pour les rejeter l'une et l'autre. Solitaire ou plurielle, la volonté n'est, en effet, susceptible d'engendrer une obligation qu'à la condition de s'être manifestée avec fermeté. Or, pour reprendre la critique développée par M. Savaux, à propos du contrat, mais qui peut tout aussi bien être transposée à l'engagement unilatéral de volonté, « il est impossible de considérer qu'un contrat (...) se noue entre le participant déçu et l'organisateur de la loterie en l'absence de véritable offre de ce dernier *qui n'a évidemment pas la volonté ferme de remettre un lot à chacun des destinataires de ce message*(7) »(8).

La critique, pour fondée qu'elle soit, doit, selon nous, être nuancée. L'appréciation de la fermeté de la volonté, exprimée dans la perspective d'un engagement unilatéral ou d'un contrat, et la décision d'y détecter la création d'une obligation relèvent du pouvoir du juge. C'est lui, et lui seul, qui, à l'issue de l'examen de la forme dans laquelle s'est coulée cette volonté, pourra décider si celle-ci présente la fermeté suffisante pour constituer un engagement unilatéral ou une offre susceptible de former un contrat à la suite de l'émission de l'acceptation. En tout cas, il n'est pas dans le pouvoir de l'entreprise de vente par correspondance d'échapper au paiement de l'obligation, en affirmant que la fermeté apparente de sa volonté était démentie par son intention réelle contraire. Sa promesse doit donc être prise au pied de la lettre. « Tel est pris, qui croyait prendre »...

Reste que c'est, sans doute, en raison des incertitudes engendrées par cette question cruciale de la fermeté de la volonté exprimée par l'entreprise que la Cour de cassation et les juges du fond se sont, le plus souvent, repliés sur le fait juridique pour retenir une obligation à sa charge.

B - Le fait juridique

7 - Fréquemment, la jurisprudence a exploité les inépuisables ressources de la vénérable responsabilité civile pour condamner les entreprises de vente par correspondance à réparer les préjudices matériel et, surtout, moral subis par le consommateur en raison de leurs fausses promesses de gain(9). En faisant miroiter au consommateur un espoir de gain illusoire, l'entreprise a commis une faute qui lui a causé un préjudice de déception qu'elle doit réparer.

Simple à mettre en oeuvre, sur le plan technique, et opportune, parce qu'elle conduit à apprécier les comportements respectifs des protagonistes, cette source spécifique d'obligation se révèle décevante dans une perspective de politique juridique, puisqu'elle ne permet guère d'attribuer à la victime le montant intégral du gain « promis ». Tenus de

respecter la loi d'airain de la réparation intégrale du préjudice, les juges accordent, en effet, fréquemment et fatalement des dommages-intérêts dont le montant est inférieur à la valeur du lot illusoire, en raison de la faible consistance du préjudice subi.

8 - A la vérité, la fluidité des sources retenues par la Cour de cassation procédait probablement, ainsi qu'on l'a écrit(10), de la variété de la forme par laquelle la promesse de gain était faite au consommateur. Soit les documents publicitaires révélaient une volonté ferme de s'engager et la voie de l'acte juridique était privilégiée par la jurisprudence ; soit la lecture de ces mêmes documents permettait d'établir simplement une volonté équivoque et seule la voie de la responsabilité civile, avec les inconvénients susvisés, restait ouverte au juge en vue de condamner l'entreprise de vente par correspondance.

9 - Aussi, est-ce, sans doute, dans le souci de contourner ces difficultés, relatives à la volonté de l'entreprise et à l'indemnisation du consommateur, que la Chambre mixte a opté pour un autre fait juridique, à savoir le quasi-contrat.

Indirectement(11), cette source avait déjà été suggérée par Mlle Viney qui, dans ses observations sous un des arrêts précités(12), avait proposé de résoudre la question en retenant l'apparence comme source de l'obligation imposée à l'entreprise de vente par correspondance. Selon cet auteur, « c'est en effet parce qu'il a pu légitimement croire, étant donné les termes de la lettre qui lui a été adressée, qu'il avait gagné le lot indiqué que le client est admis à réclamer ce lot. Sa bonne foi, fondée sur une erreur légitime, suffit à donner effet à son égard à ce qu'il a cru ». Opinion qui supposait que l'on étende le champ traditionnel d'application de l'apparence, pour l'heure réservé aux relations intéressant trois personnes, et que l'on modifie son dessein classique, qui consiste à garantir une certaine sécurité des transactions en tenant compte, dans cette perspective, de la croyance erronée, mais légitime des tiers.

Par son arrêt, la Cour de cassation va plus loin encore puisqu'elle considère que, lorsque la volonté de l'entreprise se cristallise dans l'annonce d'un gain à une personne dénommée, cette volonté déclenche, à la charge de celui qui l'a manifestée, la création d'une obligation quasi contractuelle. Au fond, le fait volontaire de l'entreprise, qui prend la forme d'une promesse de gain à personne déterminée, a pour conséquence que celle-ci est engagée, à titre de sanction, par la grâce d'un quasi-contrat, alors même qu'elle n'avait pas la volonté de s'engager.

L'intérêt du recours à la notion de quasi-contrat est évident. D'une part, il évince la discussion que suscitent les sources attachées à la volonté de s'engager, à savoir l'appréciation du caractère ferme de la volonté manifestée par le débiteur. D'autre part, il évite, au contraire de la responsabilité civile, que l'entreprise s'en sorte à bon compte en payant des dommages-intérêts dont le montant les privera de toute vertu dissuasive, en contraignant l'auteur de la promesse à la tenir, autrement dit en l'obligeant à payer l'intégralité du gain annoncé.

En dépit de ses avantages, on peut quand même se demander si le quasi-contrat ne constitue pas, pour trancher ce type de litiges, une source hasardeuse.

II - Source hasardeuse ?

Le recours à la notion de quasi-contrat, dans l'arrêt commenté, suscite deux réactions que l'on peut formuler sous la forme de deux questions, auxquelles on tentera de répondre successivement : *pourquoi pas ?* (A), d'une part, mais *à quoi bon* ? (B), d'autre part.

A - Pourquoi pas ?

10 - Si on éprouve un goût irrésistible pour le mouvement des idées, péché mignon que l'on assume, il convient de se réjouir de cet arrêt audacieux qui conduit à revoir de fond en comble la notion de quasi-contrat et à remettre l'ouvrage sur le métier.

Dans une conception classique, la qualification de quasi-contrat repose, au moins, sur trois éléments. D'abord, l'obligation quasi contractuelle a pour origine un fait volontaire spontané et désintéressé ; autrement dit, l'auteur du fait volontaire doit avoir agi, sans aucune justification juridique et dans l'intérêt d'autrui. A ce stade, il importe de préciser que ce qui distingue le quasi-contrat de l'acte juridique en général, et du contrat en particulier, consiste dans le rôle joué par la volonté dans l'une et l'autre de ces sources d'obligations. Alors que, dans l'acte juridique, la volonté est tendue vers la recherche d'effets juridiques, dans le quasi-contrat, la volonté se réduit à l'accomplissement du fait profitable à autrui, sans qu'aucune volonté de s'engager ou d'être engagé n'ait été recherchée ; au fond, donc, « (...) le rapprochement entre quasi-contrat et contrat porte ses fruits non dans l'ordre des sources de l'obligation mais dans celui des effets de celle-ci »(13).

Ensuite, le quasi-contrat, ou plus exactement l'obligation imposée par la loi à une personne, en raison du fait avantageux accompli à son profit par autrui, a pour fonction le rétablissement de l'équilibre patrimonial rompu à la suite du fait en question. A tel point que de nombreux auteurs contemporains n'hésitent pas à fédérer, dans leurs ouvrages, les quasi-contrats, à partir de cette idée et, ainsi, à les présenter comme constituant la source de « l'obligation de compenser l'avantage injustement reçu d'autrui »(14).

Enfin, le fondement des quasi-contrats réside dans l'équité : *suum cuique tribuere*. Il ne serait pas équitable d'entériner le déséquilibre patrimonial procédant d'un avantage indu, ce qui explique que la loi impose une obligation de compenser l'avantage injustement reçu d'autrui.

11 - Quelques plumes inventives ont, depuis quelque temps déjà, proposé de donner une tout autre ampleur au phénomène quasi contractuel. Quitte à les trahir, on peut les fédérer en considérant qu'elles reprennent et enrichissent l'idée de Demolombe pour lequel « un quasi-contrat, c'est quasi un contrat »(15). Au fond, selon cette doctrine, le critère du quasi-contrat réside moins dans son origine, sa fonction et son fondement, que dans le régime de l'obligation imposée par la loi à la personne qui a bénéficié du fait profitable accompli par autrui(16) ; régime presque contractuel....

Dans cette perspective, intègrent alors, en premier lieu, la catégorie des quasi-contrats, si l'on adhère à l'opinion de M. Honorat(17), les contrats forcés et les contrats fortuits.

Par contrat forcé, d'une part, il faut entendre les contrats formés par ordre de la loi en dépit de l'absence de volonté manifestée par les cocontractants, par exemple les ventes, les

échanges et les baux forcés. Avec M. Jacquet(18), on hésitera à retenir ici la qualification de quasi-contrat, à défaut de fait profitable à autrui à l'origine de ces situations juridiques. « Fait profitable à autrui », dont on a écrit, à juste titre, qu'il constitue « un authentique critère » de qualification du quasi-contrat, « dont la pertinence est absolue »(19).

Par contrat fortuit, d'autre part, il faut comprendre les hypothèses dans lesquelles deux personnes, en l'absence de rencontre préalable de volontés, accomplissent des prestations qui relèvent objectivement de l'exécution d'un contrat, par exemple la convention d'assistance ou le transport bénévole. On n'éprouvera, ici, aucune difficulté à abonder dans le sens de M. Honorat, puisque, dans ces hypothèses, on retrouve le critère du quasi-contrat, à savoir un fait volontaire spontané essentiellement profitable à autrui.

A l'initiative de M. Bénabent, entre, en second lieu, dans la famille quasi contractuelle, le contrat apparent, puisque l'apparence engendre, par l'effet de la loi, un lien de droit qui « produit exactement les effets d'un contrat »(20). Mais on ne peut s'empêcher de penser que la théorie de l'apparence cadre mal avec la figure quasi contractuelle, puisqu'elle « suppose toujours une situation à trois personnes (titulaire réel du droit, titulaire apparent, tiers contractant) et un conflit d'intérêts entre les deux extrêmes »(21), qui ne se retrouvent point dans le quasi-contrat.

On le comprend, avec cette conception novatrice, la catégorie des quasi-contrats devient extrêmement accueillante(22), puisqu'elle intègre potentiellement en son sein toutes les obligations qui ont pour origine un fait volontaire et dont le régime ressemble peu ou prou (à l'exception des règles de capacité et de preuve, une paille...) à celui des obligations contractuelles.

12 - Sauf à se tromper, la décision commentée aurait, si elle a une descendance, un effet autrement plus important sur le contenu de la catégorie des quasi-contrats que les diverses propositions doctrinales exposées ci-dessus.

En décidant que le seul fait purement volontaire de promettre un gain à autrui engendre à la charge de son auteur une obligation quasi contractuelle, la Cour de cassation se démarque, en premier lieu, très nettement, de la conception classique. En effet, l'origine de l'obligation quasi contractuelle ne réside pas alors dans un fait spontané du créancier, en l'espèce, le consommateur. Ici, au contraire, l'origine de l'obligation est recherchée dans le fait volontaire du débiteur, fait dépourvu de tout caractère désintéressé, dans la mesure où l'entreprise de vente par correspondance accomplit ce fait volontaire dans un but purement égoïste ; son fait s'inscrit, en effet, dans une stratégie commerciale mûrement réfléchie, dans laquelle toute idée d'avantage conféré au consommateur, que l'on incite à participer à un jeu, est exclue. De plus, la fonction, comme le fondement traditionnel du quasi-contrat, sont ici absents ; il n'est pas question, en effet, en imposant une obligation quasi contractuelle à l'entreprise de rétablir, au nom de l'idée d'équité, un équilibre patrimonial rompu par le fait volontaire du créancier ; l'entreprise n'a, en effet, reçu aucun avantage indu de la part du consommateur, sauf peut-être à considérer que l'envoi par le consommateur de son bulletin de jeu a augmenté le potentiel de clientèle de l'entreprise.

13 - Plus encore, la Cour de cassation prend aussi ses distances avec la conception doctrinale novatrice, dans la mesure où celle-ci peut, selon nous, être reçue, c'est-à-dire pour les contrats « fortuits ». En effet, dans les hypothèses dans lesquelles des personnes exécutent, sans aucun accord de volonté, des prestations normalement inhérentes à l'exécution d'un contrat, on retrouve toujours à la base une action spontanée profitable à autrui (assistance, transport bénévole), qu'elle émane du créancier (l'assistant) ou du débiteur (le transporteur). Or, ce critère ne se retrouve pas dans l'espèce tranchée par la Cour : pas plus le créancier de l'obligation quasi contractuelle (le consommateur) que le débiteur (l'entreprise de vente par correspondance) n'ont, par leur fait volontaire, procuré un avantage à leur « quasi-contractant ».

Au fond, la Cour de cassation opère donc une profonde mutation dans le critère de la notion de quasi-contrat. Le quasi-contrat, si l'on a bien compris sa motivation, procède désormais du fait volontaire accompli par une personne dans son propre intérêt, et qui a engendré une simple espérance légitime de gain dans l'esprit d'autrui. Le changement de perspective est alors radical, puisque le fait volontaire, qui déclenche la création de l'obligation quasi contractuelle, peut émaner du débiteur de l'engagement.

Autrement dit, par l'effet de cette décision de la Chambre mixte, le critère de l'obligation quasi contractuelle ne réside plus dans l'avantage indûment reçu d'autrui à la suite d'un fait volontaire spontané et désintéressé, mais dans l'illusion légitime créée chez autrui à la suite d'un fait volontaire, fût-il intéressé. Dès lors, un changement radical s'opère quant à la fonction du quasi-contrat. Traditionnellement appréhendé comme un mécanisme de compensation ou de restitution en faveur de l'auteur d'un fait profitable d'autrui, il constitue désormais aussi une technique de sanction des promesses sans lendemain.

14 - Indiscutablement, cet arrêt constitue une avancée considérable pour la notion de quasi-contrat ; tellement considérable que l'on peut se demander si, du coup, la Cour, par excès de générosité, ne nuit pas à la notion même de quasi-contrat en la privant de la moindre homogénéité. « Qui trop embrasse, mal étreint », en d'autres termes. Et viennent alors immédiatement à l'esprit les propos prémonitoires d'Eugène Gaudemet qui, dans son ouvrage consacré à la théorie générale des obligations, affirmait déjà, à propos de la notion de quasi-contrat : « En raison de ce vague de la notion on en a abusé. On a eu tendance à expliquer par les quasi-contrats ce que l'on était embarrassé d'expliquer autrement »(23)...

Il ne nous paraît pas illégitime, dès lors, de penser qu'avec cet arrêt la Cour de cassation a sacrifié à ce travers en transformant une source rare, hier, en une source vague, aujourd'hui... Pour le moins, si, à l'avenir, la Cour devait persister dans cette vision renouvelée de la notion, il lui appartiendrait alors d'en déterminer le domaine, avec précision, et d'en ciseler, avec rigueur, le régime.

Quoi qu'il en soit, on peut se demander si cette mutation de la notion de quasi-contrat apportera réellement un surcroît de protection du consommateur contre les pratiques commerciales douteuses des entreprises de vente par correspondance et marquera un progrès significatif, par rapport aux autres sources qui avaient été préalablement sollicitées par la Cour pour venir à sa rescousse.

B - A quoi bon ?

15 - Dans son attendu de principe, la Cour de cassation précise que « l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée *sans mettre en évidence l'existence d'un aléa* s'oblige, par ce fait volontaire, à le délivrer ».

On imagine alors que le contentieux va désormais se cristalliser sur l'existence de l'aléa en question et que les entreprises de vente par correspondance feront en sorte que les documents expédiés aux consommateurs soient rédigés avec suffisamment d'habileté pour que le juge puisse y détecter l'aléa en question.

Dès lors, on peut se demander si, peu ou prou, les mêmes incertitudes déjà dénoncées à propos des sources potentielles de l'obligation de l'entreprise, que constituent l'engagement unilatéral de volonté et le contrat, vont ressurgir, sinon sur le même objet, du moins avec la même acuité. Ainsi, alors que l'on discutait à propos de celles-ci, et à partir de l'analyse de la lettre des documents expédiés au consommateur, de la fermeté de la volonté exprimée par le prétendu débiteur de l'obligation, on va désormais, dans les mêmes conditions, pinailler à loisir sur l'existence d'un aléa qui interdira de reconnaître l'existence d'une obligation quasi contractuelle à la charge de l'entreprise. Et, ici comme là, on peut penser que les juges du fond auront tendance, par commodité, à se rabattre sur la responsabilité civile qui permet d'éluder ce type de discussion et d'accorder au consommateur une satisfaction minimum. Autant dire que l'objectif d'unification de la jurisprudence et d'apaisement du contentieux qui constituait la mission, peut-être impossible il est vrai, confiée à la Chambre mixte, risque fort de ne pas être rempli.

Tant et si bien qu'en définitive, mais peut-être par excès de pessimisme, on sera tenté de dire que, si cet arrêt constitue peut-être un grand pas (à moins qu'il s'agisse d'un grand écart) pour la notion de quasi-contrat, il ne sera qu'un petit pas pour la protection des consommateurs. Quitte à faire preuve d'audace, la Cour de cassation aurait peut-être pu consacrer l'existence d'un principe de cohérence (24) pour condamner les entreprises qui n'hésitent pas à se contredire pour échapper à leurs engagements (25). La protection des consommateurs aurait, ainsi, été assurée et le droit des sources des obligations serait encore un long fleuve tranquille...

Notes :

(1) Contrats, conc., consom., oct. 2002, comm. n° 151, obs. G. Raymond ; Petites affiches, 24 oct. 2002, p. 16, note D. Houtcieff ; V. égal. P. Bouteiller, La protection du consommateur et l'organisation d'une loterie publicitaire, JCP éd. E 2002, p. 1706.

(2) Sur ce point, V. A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 2001, spéc. n° 450 ; E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, Sirey, 1957, spéc. p. 295 ; J.-M. Jacquet, J.-Cl. civ., art. 1370-1371, v° Quasi-contrats. Généralités ; Ph. le Tourneau, Rép. civ. Dalloz, v° Quasi-contrat ; G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, Les obligations, Sirey, spéc. n° 15 ; A. Sériaux, Droit des obligations, PUF, 1998, spéc. n° 71.

(3) Entre autres, A. Bénabent, *op. cit.*, spéc. n°450 s. et 501 s. ; M. Douchy, La notion de quasi-contrat en droit positif français, Economica, 1997 ; J. Honorat, Rôle effectif et rôle concevable des quasi-contrats en droit actuel, RTD civ. 1969, p. 653.

(4) Cass. 1re civ., 28 mars 1995, D. 1996, Jur. p. 180, note J.-L. Mouralis ; D. 1997, Somm. p. 227, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1995, p. 886, obs. J. Mestre.

(5) Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, D. 2000, Somm. p. 357, obs. D. Mazeaud ; JCP 2000, I, n° 241, obs. G. Viney et II, n° 10347, obs. F. Mehrez.

(6) Cass. 2e civ., 11 févr. 1998, D. 1999, Somm. p. 109, obs. R. Libchaber ; Defrénois, 1998, p. 1044, obs. D. Mazeaud ; JCP 1998, I, n° 155, obs. M. Fabre-Magnan et n° 185, obs. G. Viney et II, n° 10156, obs. G. Carducci ; Cass. 1re civ., 12 juin 2001, D. 2002, Somm. p. 1316, obs. D. Mazeaud ; JCP 2002, II, n° 10104, obs. D. Houtcieff.

(7) C'est nous qui soulignons.

(8) Defrénois 2001, p. 693.

(9) En ce sens, V., entre autres, Cass. 1re civ., 3 mars 1988, D. 1988, Somm. p. 405, obs. J.-L. Aubert ; JCP 1989, II, n° 21313, obs. G. Virassamy ; Cass. 2e civ., 28 juin 1995, D. 1996, Jur. p. 180, note J.-L. Mouralis ; RTD civ. 1995, p. 397 ; Cass. 2e civ., 26 oct. 2001, Defrénois, 2001, p. 693, obs. E. Savaux. Pour un panorama des décisions des juges du fond retenant la responsabilité délictuelle, comme fondement de l'obligation de l'entreprise, V. Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2002/2003, spéc. n° 6800.

(10) F. Mehrez, obs. préc.

(11) Indirectement, parce qu'il faut au préalable admettre, à l'image de M. Bénabent (*op. et loc. cit.*), que l'apparence est un quasi-contrat.

(12) Obs. ss Cass. 2e civ., 11 févr. 1998, JCP 1998, I, n° 185, spéc. n° 3.

(13) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8e éd., 2002, spéc. n° 1026.

(14) Ph. Malinvaud, Droit des obligations, Litec, 2001, spéc. p. 325. - Rappr. J. Carbonnier, Droit civil, Les obligations, PUF, 2000, spéc. p. 525.

(15) Cours de Code Napoléon, t. 31, n° 53, cité par J.-M. Jacquet, préc., spéc. n° 45.

(16) En ce sens, V. notamment, A. Bénabent, *op. cit.*, n° 450, 451 et 501.

(17) Eod. loc.

(18) *Eod. loc.*, spéc. n° 84 s.

(19) Ph. le Tourneau, art. préc., spéc. n° 15.

(20) *Op. cit.*, spéc. n° 501.

(21) *Ibid.*, spéc. n° 502.

(22) V., par ex., pour une illustration, Cass. com., 26 oct. 1999, D. 2000, Jur. p. 383, note A. Pelissier ; *ibid.*, Somm. p. 328, obs. A. Honorat ; *ibid.* 1999, AJ p. 67 ; Dr. et patrimoine janv. 2000, p. 100, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; JCP éd. E 2000, p. 127, spéc. n° 7, obs. M. Cabrillac et P. Pétel. *Adde*, C. Asfar, Vers un élargissement de la catégorie des quasi-contrats, ou une nouvelle interprétation de l'article 1371 du code civil, Dr. et Patrimoine 2002, n° 104, p. 28.

(23) *Op cit.*, p. 295.

(24) En ce sens, V. D. Houtcieff, obs. préc. ss Cass. 1re civ., 12 juin 2002 et F. Mehrez, obs. préc. ss Cass. 1re civ., 19 oct. 1999.

(25) Sur cette question, V. L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, ss. la dir. de M. Behar-Touchais, Economica, 2001 et, spécialement, D. Mazeaud, Les contradictions légitimes au détriment d'autrui en droit des contrats, p. 127

Document n° 8 : D. Fenouillet, « Loteries publicitaires : pour un droit efficace ! »

La jurisprudence de la Cour de cassation ne suffit pas à endiguer les pratiques de loteries publicitaires. Quelles sont les voies qui peuvent alors être explorées ?
Plaidoyer pour une lutte efficace contre les chimères des loteries publicitaires ! - Alors que la Cour de cassation maintient le cap du quasi-contrat, avec ses atouts (délivrance du gain) et ses inconvénients (exclusion de l'option de compétence territoriale ouverte en matière contractuelle), les entreprises de vente par correspondance poursuivent leur politique agressive, ce qui ne peut que conduire à relativiser l'efficacité de la règle de droit en la matière, et à s'interroger sur d'éventuelles améliorations du droit positif.

Que l'on pardonne au chroniqueur de faire état de sa dernière expérience personnelle (car lesdites expériences sont légion !) pour illustrer le propos. Réception, par courrier déposé le 26 avril et reçu le 31 avril 2007, d'un message adressé par une société de vente par correspondance bien connue à Mme Fenouillet Dominique. Sur l'enveloppe, deux mentions : l'« opération » est désignée « chèque bancaire 3 000 euros » ; l'« objet » est identifié comme étant « validation de votre adresse avant l'envoi de votre chèque ». À l'intérieur de l'enveloppe, une lettre de deux pages et un bon de participation. La lettre est un modèle du genre. La première feuille cumule, au recto, les fausses annonces de gain, avec utilisation très tendancieuse des caractères gras : « Laissez-moi vous adresser toutes mes félicitations ! », « L'information est donc officielle et définitive : Mme Fenouillet, vous allez bien recevoir un chèque dans le cadre de notre opération chèque bancaire de 3 000 (euros)" », « D'ores et déjà, je vais donc faire le nécessaire pour que ce chèque* vous soit adressé dès que possible » (l'astérisque renvoie en bas de page à la mention « chèque bancaire ou chèque achat »), « afin de déclencher l'envoi, il me manque néanmoins une confirmation de votre adresse pour valider votre participation (...) »). La seconde page est encore plus malhonnête : il s'agit de la photocopie d'un chèque émanant de la société en question, de 3 000 euros, libellé à « Notre cliente gagnante » ; mais pour conforter la conviction que le gain est définitif, est collé sur la feuille un post-it jaune portant, en bleu et en script, la formule suivante : « copie du chèque de 3 000 euros à adresser à Mme Fenouillet ». Il faut lire le verso de la première page, pour découvrir, en bas, en petits caractères, un encart intitulé « Extrait de règlement de la loterie Chèque bancaire de 3 000 euros !" », encart indiquant que la société en question organise une loterie sans obligation d'achat, définissant les conditions de la participation, et précisant : « aucun destinataire ne peut être certain à réception des documents d'être le gagnant du lot principal (un chèque de 3 000 euros) mis en jeu » (précision ne prenant même pas une ligne entière sur les quatorze lignes du texte de l'encart).
Le tout est suffisamment bien fait... pour que le chroniqueur, pas totalement profane en la matière, ait dû lire à plusieurs reprises le document avant de conclure qu'il ne s'agissait effectivement que d'une participation à un jeu et... pour que son conjoint et ses enfants aient suggéré d'écrire car tout cela se discutait, les uns étant d'avis que Mme Fenouillet avait bien gagné, les autres considérant que cela n'était pas clair !

Sans doute la jurisprudence de la Cour de cassation permettrait-elle éventuellement d'agir en délivrance du gain. On se souvient de la décision rendue par la première Chambre civile le 13 juin 2006 dans laquelle la Cour de cassation a posé pour principe que « l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain » (RDC 2006, p. 1115). Or, ici, sans doute est-ce au moment même de l'annonce du gain, et non dans un courrier ultérieur, que l'aléa est présenté. Mais l'ambiguïté des documents est organisée avec suffisamment de brio, en utilisant la diversité des emplacements (recto et verso), des caractères (gros et petits, gras et simples, écrit à la machine ou à la main, en noir ou bleu), des formules (« officiel et définitif », « confirmation », « participation »), des temps (présent, passé et futur), pour que plusieurs lectures soient nécessaires pour déterminer si oui ou non il y a gain. Mais les aléas de tout procès, joints au temps qu'il faut y consacrer et à la relative faiblesse de l'enjeu, expliquent que la destinataire ici concernée n'introduira aucune demande en justice, comme la plupart des destinataires d'ailleurs. Et l'on comprend ainsi comment de telles pratiques ont pu se multiplier jusqu'à être le fait d'entreprises ayant pignon sur rue - comme ici !

Or le problème est que de moins attentifs ou de plus naïfs seront sans doute abusés et répondront à la demande de confirmation. Bon nombre passera même commande. En quoi consiste en effet la confirmation de participation ? La première page du courrier se termine sur cette précision : « Bon à savoir, en passant votre commande au... (suit un numéro de téléphone) ou sur... (suit l'adresse d'un site internet), en indiquant... (suit un numéro de code), la validation de votre adresse et de votre participation sera automatiquement prise en compte ». Et ce n'est qu'au verso, et toujours en petits caractères, que l'on apprend que la participation est sans obligation d'achat. Qui plus est, le bon de participation est porté sur la même feuille que le bon de commande et ce ne sont que des pointillés qui indiquent qu'il peut en être détaché. Mieux, il faut joindre au bulletin de participation une demande écrite pour obtenir le remboursement des frais d'accès à la loterie, bref pour que la gratuité imposée par la loi devienne effective !

Une telle organisation matérielle est-elle conforme à la loi ? On sait que l'article L. 121-36 ne permet que les opérations publicitaires qui « n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit » et qu'il précise en outre que « le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service ». Quant à l'article R. 121-11, son alinéa 2 prévoit que ces éléments (bon de commande, extraits du règlement, présentation des lots, bulletin ou bon de participation) doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible l'indication de l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention. L'incertitude, ici, est de deux natures. S'agissant d'abord du remboursement des frais de participation sur demande écrite du consommateur, on peut se demander s'il suffit à assurer l'absence de « dépense sous quelque forme que ce soit », d'abord parce qu'il n'intervient que sur demande écrite, ensuite parce que le remboursement de la dépense n'empêche qu'une dépense a été faite, enfin parce que la rédaction d'une demande écrite suppose d'utiliser papier et encre, en quoi il y a dépense, minime certes, mais dépense tout de même. S'agissant, ensuite, de la présentation formelle du bon de participation, il n'est pas sûr qu'elle suffise au regard de la loi, là encore à deux points de vue. On peut s'interroger sur le point de savoir si de simples pointillés indiquant la possibilité de séparer les deux documents suffisent à considérer que le

bulletin de participation et le bon de commande sont distincts. La Cour de cassation considérant malheureusement que la question du caractère distinctif relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim., 5 avr. 1995, Bull. crim., nº 151 ; Cass. crim., 30 oct. 1995, Bull. crim., nº 334), les décisions ne sont pas toujours très rigoureuses : si le Tribunal d'instance de Paris a ainsi jugé qu'une présentation sur une même feuille d'un bon de participation à peine différencié du bon de commande et sans indication graphique de détachabilité ne suffisait pas, puisque bon de participation et bon de commande devaient être envoyés en même temps (23 nov. 1995, Contrats, conc. consom. 1996, comm. nº 92, note G. Raymond), et si la Cour d'appel de Paris a considéré, le 10 mars 1994 (Contrats, conc. consom. 1994, comm. nº 232, obs. G. Raymond), que la situation du bon de commande et de participation sur la même page sur laquelle on lisait « pour commander vos articles, veuillez utiliser ce document qui vous permet également de réclamer votre prix en espèces » ne respectait pas l'exigence légale, cette même cour a considéré, le 6 novembre 1996, que le caractère détachable d'un bon de participation rédigé en bleu sur fond jaune quand le bon de commande était en rouge sur fond blanc suffisait, même en l'absence de prédécoupage (D. aff. 1997, p. 407). On peut en outre se demander si le bon de commande et le bulletin de participation respectaient l'exigence de comporter « en titre de manière particulièrement lisible (...) l'objet du document », alors que le titre « bon de participation » est mentionné dans une bande grise le rendant peu visible et que le bon de commande ne comporte quant à lui aucun titre mais simplement la phrase suivante, il est vrai en rouge (!) : « choisissez la commande rapide et recevez votre colis dès demain ». Là encore, donc, le moins que l'on puisse dire est que le respect par la loterie des règles du droit de la consommation n'est pas scrupuleux ! Mais là encore, la question relève de l'interprétation judiciaire. Et l'on ne peut, là encore, que déplorer l'incertitude de la solution, qui, rendant aléatoire le résultat d'un procès, incite bien peu à le tenter, et fragilise d'autant la protection du consommateur.

Quelle est, en effet, la conséquence de cette double ambiguïté (sur l'existence du gain, sur la possibilité de participer au jeu gratuitement et sans commander) ? Elle permet d'abuser certains consommateurs et d'obtenir qu'ils fassent des commandes qu'ils n'auraient pas faites sans elle.

La conclusion qui s'impose est alors très simple : puisque la jurisprudence de la Cour de cassation ne suffit pas à endiguer de telles pratiques professionnelles, et que leur prolifération atteste qu'elles sont certainement fructueuses en termes de commandes, d'autres voies s'imposent.

La première consisterait à renforcer l'encadrement spécial des loteries.
Le législateur devrait modifier les articles L. 121-36 et R. 121-11, alinéa 2, et renforcer les exigences de gratuité (en précisant que « la gratuité de la participation est automatique et ne doit pas dépendre d'une demande du consommateur ») et de distinction des bon de commande et bulletin de participation, en accentuant la différence de terminologie (la formule « bon » de participation devrait être prohibée avant d'éviter toute confusion avec le bon de commande) et en précisant que « le bulletin de participation doit figurer sur un écrit matériellement autonome de tout bon de commande ». Mieux, la finalité de ces loteries ambiguës étant d'obtenir des commandes qui n'existeraient pas sans l'illusion ainsi créée, le moyen de lutte le plus radical contre ces pratiques consisterait à s'efforcer d'empêcher tout envoi « lié » d'un bon de commande et d'une participation à une loterie. Le législateur pourrait alors modifier à cet effet l'article L. 121-36 du Code de la

consommation et préciser que « les opérations de loteries publicitaires ne peuvent accompagner des offres de vente ou propositions de commande ».

Mais la pusillanimité dont le législateur a récemment fait preuve à l'égard du droit de la consommation (v. le sort peu enviable du projet de loi renforçant la protection des consommateurs, RDC 2007, p. 355) conduit plutôt à espérer une intervention de la Cour de cassation. Le premier effort devrait porter sur l'interprétation de l'article L. 121-36 du Code de la consommation : plutôt que de renvoyer le caractère « distinct » du bon de commande et du bon de participation au pouvoir souverain des juges du fond, la Cour devrait poser comme principe que bon de commande et bulletin de participation doivent être « présentés sur des formulaires matériellement distincts ». L'article R. 121-11 se borne, il est vrai, dans son alinéa 2, à prévoir que les quatre éléments que sont bon de commande, bulletin ou bon de participation, extraits du règlement, présentation des lots, doivent figurer chacun « dans une partie distincte » comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention. Mais cette formule souple de « partie distincte » peut être interprétée comme renvoyant à un « formulaire distinct matériellement ». Pour donner force à la protection du consommateur, la Cour de cassation ne pourrait-elle s'inspirer ici de la rigueur formaliste dont elle fait preuve en matière de démarchage (v. Cass. civ. 1re, 21 nov. 2006, pourvoi no 05-20706, commenté infra, e) ? Le second effort pourrait porter sur l'efficacité du quasi-contrat. La Cour de cassation ne devrait-elle pas considérer que « l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mis en évidence sans aucune ambiguïté ». Elle pourrait même préciser qu'« est ambiguë la juxtaposition de formules donnant à penser, les unes qu'il y a gain définitif, les autres qu'il ne s'agit que d'une participation à une loterie ».
La seconde consiste à suggérer à la Cour de cassation de consacrer les dommages-intérêts punitifs. La solution, théoriquement, est discutable : la faute commise par le professionnel bénéficiera au consommateur nonobstant l'absence de dommage ou bien au-delà de la faiblesse du dommage (v. RDC 2007, p. 331) ! Mais l'exemple ici analysé atteste qu'elle est peut-être nécessaire.

En toutes hypothèses, il faut faire cesser des pratiques professionnelles qui, pour être déloyales, n'en sont pas moins tout à fait profitables, et faussent le jeu de la concurrence (sauf à suggérer à chaque professionnel d'adopter le même comportement et de porter la concurrence jusqu'à la déloyauté !) en même temps qu'elles portent préjudice, peut-être pas à tous les consommateurs, mais certainement à certains d'entre eux. Et il conviendrait de ne point trop attendre. Ne serait-il pas regrettable que le droit français doive, une fois encore, recevoir la leçon de la Cour de justice pour mettre un terme à des procédés malhonnêtes ? Or n'est-ce pas ce qui risque d'arriver, s'agissant de ce qui semble bien relever des « pratiques commerciales déloyales » condamnées par la directive « pratiques commerciales déloyales » du 11 mai 2005 (sur quoi, v. RDC 2005, p. 1059) ? N'y retrouve-t-on pas en effet les deux conditions posées en général par l'article 5, à savoir un comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle et susceptible d'altérer la liberté de choix ou de conduite du consommateur et de l'amener à une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise sinon ? La directive ayant prévu qu'elle devait être transposée dans un délai de trente mois à compter de son entrée en vigueur, il ne serait peut-être pas inutile d'y procéder rapidement, et autrement que par voie d'ordonnance s'il vous plaît !